

Vistos,

DANIELTON FERNANDO PEREIRA ALVAREZ e LUDMAR ANTONIO LUIS LOPES ALVARES, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, combinados com o art. 40, inciso III da Lei nº11.343/06, porque em data, horário e local incertos, perdurando até o dia 19 de fevereiro de 2020, nesta cidade e comarca de Guararapes/SP, os denunciados supracitados associaram entre si e com outras pessoas não identificadas para o fim reiteradamente praticar crime de tráfico ilícito de drogas.

Consta também que, no dia 19 de fevereiro de 2020, às 22h10min, no cruzamento das Ruas Albino Gomes e João de Souza, bairro Jardim Pioneiro, nesta cidade e comarca de Guararapes-SP, Danielton previamente associado e mantendo unidade de desígnios com Ludmar e outras pessoas não identificadas, trazia consigo, para fins de tráfico, nas imediações de unidades escolares e de praça de recreação, 7,46g (sete gramas e quarenta e seis centigramas) da substância vulgarmente conhecida por Cocaína, na forma petrificada, divididos em 21 (vinte e uma) porções, envoltas em fita crepe e plástico, droga esta que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tudo conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, laudo de constatação preliminar de fls. 16 e laudo toxicológico definitivo de fls. 51/53.

Devidamente notificados, os requeridos ofertaram defesas preliminares às fls. 377/378 e 404/406, que não foram aptas a ensejar a rejeição da denúncia.

Com relação ao requerido Ludmar Antônio Luiz Lopes Alvares, a denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2022 (fls. 389/390). Já, com relação ao requerido Danielton Fernando Pereira Alvares, a denúncia foi recebida em 03 de fevereiro de 2022 (fls. 413/416).

Em audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas e, ao final, os requeridos foram interrogados (fls. 446/447).

O Ministério Público, após tecer considerações de fato e de direito sobre o caso, pleiteou pela procedência da ação penal nos termos da denúncia.

A Defesa de Ludmar Antônio Luiz Lopes Alvares pugnou pela absolvição do acusado diante da fragilidade probatória, na forma do art. 386, inciso V do CPP.

Subsidiariamente, pleiteou a fixação do regime inicial de pena como sendo o semiaberto (fls. 450/459).

Já a Defesa de Danielton Fernando Pereira Alvarez pugnou pelo reconhecimento do tráfico na forma privilegiada, prevista no art. 33, §4º da Lei nº11.343/06; a aplicação da atenuante da confissão espontânea; a absolvição quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei nº11.343/06; a fixação a pena no mínimo legal, em regime inicial semiaberto (fls. 460/465).

É O RELATÓRIO.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, proposta em face de Danielton Fernando Pereira Alvarez e Ludmar Antônio Luis Lopes Alvares, a quem são imputadas as práticas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº11.343/06, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III da Lei nº11.343/06.

A materialidade do crime está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01/02; Boletim de Ocorrência de fls. 03/05; Auto de exibição e apreensão de fls. 17/18; Auto de constatação prévia de fls. 16; laudo toxicológico de fls. 51/53; documentos de fls. 75/82 e prova oral colhida nos autos.

A autoria é, do mesmo modo, incontestada.

A testemunha Clodoaldo de Oliveira Medeiros, policial militar, afirmou que estavam em patrulhamento, quando foi paga uma ocorrência na Rua Albino Gomes com a Rua João de Souza, onde estaria um indivíduo de apelido "Zé Galinha", sem camisa e com uma bermuda listrada, sentado em uma cadeira, praticando o crime de tráfico de drogas.

A denúncia apontava, ainda, que o requerido guardava os entorpecentes no tubo dessa cadeira de área. Foram até o local e localizaram Danielton, que apresentava as características passadas pelo COPOM. Em busca pessoal, encontraram um celular Samsung J4, cerca de R\$60,00 em dinheiro e um vidro de perfume. Disse terem

revistado a cadeira de área, mas que nada foi localizado em suas ferragens. Posteriormente, observaram que dentro do vidro de perfume, havia objetos em seu interior. Abriram o frasco e localizaram vinte e uma pedras de crack. Indagado a respeito, o acusado afirmou que estava desempregado e que havia sido procurado por "Marcião" para realizar o tráfico de drogas na região, tendo anuído à proposta. Relatou, ainda, que Danielton informou que a droga era entregue por Ludmar, que era responsável por distribuir os kits na região. O requerido ainda lhe confidenciou que naquele dia pegou 28 pedras de crack, que venderia por R\$10,00 cada. A cada dez pedras vendidas, lucraria por quatro. Acrescenta, ainda, que próximo ao local da abordagem existe uma creche, uma escola infantil e uma praça de recreação, em que existe uma frequência elevada de jovens, sendo que ao lado da praça, havia uma horta comunitária. Ao final, apontou que já existiam informações de que Ludmar praticava o crime de tráfico de drogas no local, assim como Danielton. Inclusive, Danielton foi novamente preso por tráfico de drogas após estes fatos.

No mesmo sentido, é o depoimento de Ivanir Ferreira de Souza, policial militar, que afirmou que, no dia dos fatos, foram solicitados via COPOM, para que se dirigissem ao endereço indicado na inicial, em razão de uma denúncia de que um indivíduo conhecido como "Zé Galinha", que estava sem camisa, com uma camiseta nos ombros e uma bermuda estaria praticando o crime de tráfico de drogas no local. Chegando ao endereço indicado, identificaram a pessoa descrita na denúncia como sendo Danielton, que portava algumas porções de drogas, dinheiro e um aparelho celular. Acrescentou que a droga estava escondida dentro de um frasco de perfume. Indagado a respeito, o requerido confessou informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, com início a cerca de duas semanas, porque estava desempregado. Disse ter sido convidado por Márcio Pereira Dias, vulgo "Marcião" e que a droga era entregue por Ludmar. Asseverou, de outra parte, que em audiência de custódia o requerido foi solto e, dias após, foi novamente preso pela prática do crime de tráfico de drogas no mesmo local. Sublinha que o local em que o requerido foi abordado, existe uma creche, uma escola infantil, uma praça com bastante movimento e uma horta comunitária. O referido local poderia ser utilizado para encontrar clientes, pois frequentado por muitos jovens. Menciona, por fim, que o tráfico de drogas, atualmente, ocorre com distribuição de pequenas quantidades, posto que caso ela seja perdida, o prejuízo não é muito grande. O próprio acusado afirmou que estava com vinte e oito pedras de crack e que a cada dez pedras, quatro era seu lucro pessoal. Por fim, ponderou que não conhecia Danielton, mas tinha informações a respeito de Ludmar e seu envolvimento com o tráfico de drogas..

Em seu interrogatório judicial, o requerido Danielton Fernando Pereira Alvarez afirmou que, no dia descrito na denúncia, estava desempregado e precisava de dinheiro. Confessa que estava vendendo drogas no dia dos fatos e já havia vendido dez pedras, antes de ser abordado. Disse que cobrava R\$10,00 por pedra e que já estava vendendo o entorpecente há dois meses. Quanto às conversas mantidas com Ludmar em seu celular o requerido afirmou que ambos são amigos e que não possuem relacionamento comercial. Com relação às tampas vazias, mencionadas nas conversas, o requerido afirma que não comercializa cocaína, apenas crack, apontando, ainda, que as "novidades", também mencionadas nas conversas, diziam respeito à droga que ele usava. Recusou-se a informar quem lhe fornecia o entorpecente.

Ludmar Antônio Luís Lopes Alvarez, em seu interrogatório judicial, afirmou que é primo do requerido Danielton, mas que não estava envolvido com a prática do crime de tráfico de drogas. Com relação às mensagens encontradas em seu telefone celular, a peneira apontada dizia respeito ao seu trabalho como pedreiro. Disse que o requerido Danielton pediu as tampas de caneta mencionadas nas mensagens, sem que saiba dizer o motivo, e que as "novidades" apontadas diziam respeito a mulheres. A prova oral produzida em Juízo é segura e está corroborada por aquela colhida na fase administrativa.

Os depoimentos dos policiais são harmônicos e coesos e não foram abalados por nenhum vestígio de irregularidade.

O policial militar relatou, com clareza, ter sido paga uma ocorrência pelo COPOM, informando que uma pessoa, sem camisa e de bermudas, estava comercializando drogas no local apontado na denúncia. Chegando ao local, surpreenderam Danielton, que

apresentava as características que lhe foram passadas e, em busca pessoal, localizaram dentro de um vidro de perfume, vinte e uma pedras de crack. Quando indagado, o requerido confessou que estava traficando, porque estava desempregado, dizendo ainda que recebia o entorpecente de Ludmar, responsável pela distribuição da droga na região.

Inexiste qualquer prova, indício ou sugestão de que tivessem os policiais alguma motivação lógica para falsamente incriminar os acusados, encontrando-se, destarte, superada qualquer tese acerca de eventual contraditoriedade de tais depoimentos ou que não possuam valor probante, até porque, como os civis, são pessoas de igual credibilidade e responsabilidade.

A propósito, sobre o tema, iterativa é a jurisprudência, de que o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não se podendo cogitar de suspeição ou inidoneidade derivada só de sua condição funcional. Não há qualquer elemento nos autos que possa macular o depoimento dos agentes públicos que, ao que tudo indica não tinham motivos aparentes para desejar incriminar os requeridos.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES, RECEPÇÃO DOLOSA E POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO - Réu que se insurge apenas e tão somente contra a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas - Autoria e materialidade desse delito comprovadas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Pena e regime prisional fixados com critério e conservados - Recurso ministerial que visa o afastamento do redutor do § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 -

Impossibilidade - Réu primário, sem que exista prova indubitosa de que se dedicasse a atividades criminosas ou mesmo integrasse organização dessa natureza - Recursos desprovidos". (TJSP; Apelação Criminal 0027156-80.2018.8.26.0050; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020)

"Apelação. Tráfico de drogas. Pleito Ministerial visando a reforma da sentença com o afastamento da figura do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial fechado com o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. 2. Dosimetria da pena que não comporta reparos. Quantidade de drogas que não era excessiva. Processo em andamento que não pode ser utilizada para agravar a situação do acusado. Reconhecimento da figura do tráfico privilegiado com redução no patamar máximo o que permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime inicial aberto. 3. Recurso ministerial conhecido e improvido". (TJSP; Apelação Criminal 1500080-07.2018.8.26.0535; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Arujá - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020)

De outra parte, as conversas obtidas do celular apreendido com Danielton, indicam, sem sombra de dúvidas, que os requeridos exerciam a prática do crime de tráfico de drogas. Ao que tudo indica e, segundo se apreende das conversas constantes do aparelho telefônico, Ludmar repassava as drogas para Danielton, além de pedir-lhe que guardasse outros instrumentos destinados ao crime de tráfico de drogas.

É de se notar que, quando indagados a respeito do pedido de Ludmar, para que

Danielton guardasse as tampas de caneta em sua casa, ambos não conseguiram apresentar qualquer justificativa ao pedido. No tocante à mencionada “novidade”, Danielton afirmou que se tratava da droga utilizada para seu consumo próprio, embora em nenhum momento tenha indicado ser usuário de drogas, enquanto Ludmar afirmou que se tratava de mulheres, que ambos conheceram. Ficou claro, portanto, que tanto Ludmar quanto Danielton praticavam o crime de tráfico de drogas. Enquanto Ludmar distribuía o entorpecente na região, entregando um kit a Danielton, este comercializava a droga, próximo a uma praça de recreação, uma creche e uma escola infantil.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Em outras palavras, ainda que os policiais não tenham visto os réus efetivamente entregando entorpecentes, em nada os socorre, pois, o artigo 33 da Lei 11.343/06 é um tipo misto alternativo, que dentre os núcleos penais, estabelece a conduta de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, para fins de tráfico ilícito, substância entorpecente.

Conclui-se, pois, que todas as circunstâncias indicam que as drogas apreendidas com o requerido Danielton eram destinadas à prática de tráfico ilícito e que lhe eram fornecidas por Ludmar.

As provas, portanto, comprovam a prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 pelos acusados, já que suas condutas se subsumiram aos elementos objetivos do respectivo tipo penal.

Quanto ao delito de associação para o tráfico, cita-se o magistério de Guilherme de Souza Nucci: “Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico” (Leis Penais e Processuais Anotadas 1. ed., 2. tir. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2006).

Da análise de toda a situação, é possível constatar a existência de associação para o tráfico entre ambos os requeridos.

Dos autos apreende-se que ambos são parentes e que mantinham bastante próximo e amistoso, sem que possuíssem qualquer relacionamento comercial. Apreende-se das conversas registradas às fls. 75/82:

LUDMAR: “Ô, fala isso aí o zé galinha, é o seguinte mano, deixa eu falar pra você viado, e o trole que eu deixei com você mano, o que você fez com aquela gringa lá doido? Aí, se você já vendeu, ou pá não sei qualquer fita mano, mas ó a dívida que tem com nós aí mano?”

DANIELTON: “Vê aí ó, se quiser que eu levo lá eu levo, baguio não tá aqui não mano, cê é louco tiozão? Baguio tá guardado, cê acha que eu ia ficar moscando com essa caminhada aqui, cê é louco tio, vou me arrastar mano, tá tirando, baguio já tá moiado, e cê acha que eu vô ficar com a caminhada em cima ainda, cê é louco? Pode pá mano, se quiser que eu lá eu levo tiozão, fica tranquilo, esquentar a cabeça não maluco, cê acha que eu vou arrastar a caminhada? Mais eu ainda que sou novo aqui no flash, cê é louco?”

LUDMAR: - "E aí o frango, comedião, sai aí fora da sua casa aí mano, sai com um real desse aí, entendeu viado, mas não demora não, o maluco tá aí" (fls. 79)

Nota-se, portanto, que Danielton recebia as drogas e as comercializava, prestando contas a Ludmar.

Restou, portanto, comprovado o caráter duradouro da união entre os réus, elementos aptos para a incidência do crime previsto no artigo 35 da lei 11.343/06.

Sendo assim, de rigor a condenação dos requeridos pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº11.343/06.

Quanto ao crime de tráfico de drogas